

我国刑事诉讼中的证据准入制度及其完善

艾 明^{*}

内容提要 现代刑事诉讼中的证据准入是指由法院来审查证据是否具备进入审判阶段法庭调查程序、成为证据调查对象的资格。历经十余年发展,我国已初步构建起刑事诉讼中的证据准入制度,形成了符合证据审查发展趋势的“证据准入—证据评估”二元阶层结构。但从比较法、司法实践以及未来改革方向角度审视,该制度在实体和程序方面仍然存在一些问题。未来我国应适当扩大证据准入制度筛选证据的范围,将证据的适格性确定为证据准入制度的核心概念,构建以庭前会议为主的证据准入审查程序,采取“异议+释明”模式减轻被告人的程序启动责任。

关键词 刑事诉讼 证据准入 证据评估 证据收集的合法性 证据的适格性

目 次

- 一、问题的提出
- 二、刑事诉讼证据准入制度的理论证成
- 三、证据收集的合法性与相关概念的区别
- 四、刑事诉讼证据准入制度存在的问题
- 五、刑事诉讼证据准入制度的完善

^{*} 西南政法大学刑事检察研究中心教授。本文系中国法学会 2025 年度部级法学研究课题“监察执法和刑事司法衔接中的协商机制研究”(项目批准号:CLS(2025)D06)的阶段性成果。

一、问题的提出

现代刑事诉讼证据审查的发展趋势是形成“证据准入—证据评估”相分离的二元阶层结构。^①这种阶层结构包含实体与程序双重意蕴:从实体层面而言,事实认定者不应仅关注证据的真实性、可靠性等涉及事实认定准确性的认识因素,还应关注证据收集、使用过程中涉及的人权保障、防止偏见等法律价值和外部政策因素。从程序层面而言,为了保障法律价值和外部政策因素得到优先审查,需构建前置的、较为独立的证据准入审查程序。

观察比较法,上述二元阶层结构体现得较为明显。美国以可采性为核心概念,将众多法律价值和外部政策因素优先纳入审查视野,并借助“法官—陪审团”二元审判结构的天然优势,形成了前置、独立的证据准入审查程序。日本以证据能力为核心概念,将人权保障、正当程序等法律价值因素优先纳入审查视野,并借助理前整理程序的证据裁定制度实现了“证据准入—证据评估”的程序分离。^②我国台湾地区也以证据能力为核心概念,实现了证据审查要素的阶层区分。在民众参与刑事审判的案件中,要求职业法官应于准备程序终结前就系争证据的证据能力有无先为裁定。证据经法官裁定无证据能力的,不得于审判期日主张或调查之。在其他一般案件的审理中,司法实务部门也在积极探索构建相对独立的证据准入审查程序。^③就连通常被认为并无前置、独立证据准入审查程序的德国,实际上也借助侦查法官制度和证据调查异议制度实现了预先筛选证据的功能。以证据调查异议制度为例,在“私人秘密录音案”中,被告人提出证据调查异议,反对法庭播放被害人女友秘密录制的录音带,法庭认同此异议,裁定不予调查该证据,被告人最终被判无罪。^④

从文义上分析,“准入”本是经济学领域的重要术语,意指政府或其授权机构准许符合条件者进入某行业或领域从事生产经营活动。^⑤依其本义,在刑事诉讼中使用“证据准入”一词,似乎意指准许符合条件的证据进入刑事诉讼领域用于证明活动。然而,简单照搬“准入”的经济学含义来理解“证据准入”在刑事诉讼中的含义并不妥当。这是因为,刑事诉讼和从事生产经营活动的行业或领域不同,其由立案、侦查、起诉、审判等多阶段构成,每一阶段负责事实认定的主体各异,并且随着诉讼阶段的推进,事实认定逐渐深入。因此,仅将“证据准入”理解为准许符合条件的证据进入刑事诉讼领域从事

① 参见吴洪淇:《刑事证据审查的基本制度结构》,载《中国法学》2017年第6期,第170页。

② 参见[日]田口守一:《刑事诉讼法》(第7版),张凌、于秀峰译,法律出版社2019年版,第352-354页。

③ 参见苏凯平:《民众参与刑事审判程序的证据能力判断:兼论鉴定证据之证据能力判断标准》,载《台大法学论丛》第50卷第4期(2021年),第1935页。

④ 参见王士帆:《禁止不计代价发现真实与私人不法取证——德国联邦最高法院刑事裁判BGHSt 14, 358译介》,载《司法周刊》第1599期(2012年),第5页。

⑤ 参见《现代汉语词典》(第7版),商务印书馆2016年版,第1728页。

证明活动并无意义,因为这种理解明显提前了证据准入的时点,大幅降低了证据准入的门槛,不利于最终的事实认定者筛选证据,实现法律的多重价值。

那么,在刑事诉讼中,证据准入究竟应定位在哪一阶段,什么时点呢?答案显而易见,应当定位在审判阶段最合理。原因在于:首先,就心理动力而言,心理学的自我宽恕定律显示,个体欠缺自我纠错的动力。^⑥在审前阶段,负责事实认定的主体——侦查机关和检察机关亦是证据收集的主体,同时承担着追诉职能,依据自我宽恕定律,这会极大削弱侦查机关和检察机关排除证据的心理动力,不利于发挥证据准入的筛选证据功能。而在审判阶段,负责事实认定的主体——法院并不直接收集证据,也不承担控诉职能,其居于客观、中立、超然的地位,也就具有更强的心理动力去排除相关证据,成为证据准入审查最合适的主体。其次,在审判阶段,法院享有事实认定的终局决定权,由法院在该阶段职司证据准入审查之责,更有利于保障事实认定的准确性,维护多元的法律价值,并向前发挥导正效应,引导侦查机关规范取证,向后发挥把关作用,避免不适格的证据演变为定案根据,污染事实认定者心证。对此,有论者指出,侦查机关、检察机关、审判机关都有排除非法证据的责任,但人民法院的审判是决定被告人是否有罪、被判处何种刑罚的关键阶段,也是非法取得的证据能否被排除不作为定案根据的关键阶段。^⑦

正由于此,以上比较法考察的国家和地区,莫不将证据准入的阶段和时点锚定在审判阶段的法庭调查环节。由此,现代刑事诉讼中的证据准入是指,由法院来审查证据是否具备进入审判阶段法庭调查程序、成为证据调查对象的资格。“证据准入是审查证据进入审判程序的资格。”^⑧事实上,在我国刑事诉讼法学界,研究证据准入还存在其他两条路径:一是研究证据材料准入整个刑事诉讼领域的证据资格;二是研究证据是否具备定案根据的资格。在笔者看来,前者涉及的证据审查要素,如是否具备最低限度的关联性、是否属于法定的证据种类、取证主体是否获得刑事诉讼法的特别授权等,属于相对简单且容易识别的因素,其虽具有一定的证据筛选功能,但总体上筛选的数量很少。后者受限于我国对定案根据的规定含义多元,类型杂糅,^⑨加之对定案根据资格的审查欠缺前置、独立程序的保障,实践中容易出现混淆判断的情况,不利于形成“证据准入—证据评估”相分离的二元阶层结构。有鉴于此,本文主要从证据是否具备进入审判阶段的法庭调查程序、成为证据调查对象的资格这一角度,研究我国刑事诉讼中正在形成的证据准入制度,期望通过研究拓展、充实刑事证据法学理论、服务刑事诉讼实践,并助力构建中国刑事诉讼法学自主知识体系。

⑥ 参见刘凌、马旭颖、沈悦:《西方自我宽恕模型研究进展》,载《辽宁师范大学学报(社会科学版)》2013年第2期,第211页。

⑦ 参见全国人大常委会法制工作委员会刑法室编:《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法的决定〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2012年版,第63页。

⑧ 前注①,吴洪淇文,第170页。

⑨ 参见纵博:《不得作为“定案根据”条款的学理解析》,载《法律科学》2014年第4期,第74页。

二、刑事诉讼证据准入制度的理论证成

传统上,我国刑事诉讼将查明案件事实真相视作优先目的,受此影响,在法庭调查程序开始前,法院基本不会对侦查机关收集的证据进行筛选,而是照单全收,任凭这些证据全数涌进法庭调查程序,侦查中心主义得以形成。这种情况下,法院的事实认定活动欠缺独立性,成为对侦查结论的单纯确认。^⑩随着2004年人权入宪以及一系列冤假错案的曝光,我国立法机关和最高司法机关开始正视传统做法的不足,探索建立证据准入制度。这种制度探索发轫于2010年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》(以下简称2010年《排非规定》),经由2012年修改的《刑事诉讼法》、2012年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称2012年《刑事诉讼法解释》)、2017年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》(以下简称2017年《严格排非规定》)、2017年最高人民法院印发的《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程(试行)》(以下简称2017年《排非规程》)、2021年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(以下简称2021年《刑事诉讼法解释》)的发展,最终在2024年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发的《办理刑事案件排除非法证据规程》(以下简称2024年《排非规程》)得到初步定型。可以说,历经十余年的实践探索,我国已经初步构建起刑事诉讼证据准入制度。

(一) 支撑证据准入制度形成的重要举措

证据准入制度的诞生是形成“证据准入—证据评估”二元阶层结构的重要标志。该制度具有双重特征:在实体上,将某些法律价值和外部政策因素单独作为优先级审查,实现实体审查因素的阶层区分;在程序上,存在前置、较为独立的证据准入审查程序。目前,我国已在这两个方面推出诸多举措,初步构建起证据准入制度。

其一,确立非法证据排除规则,实现实体要素的优先分层审查。实体要素是指,在审查证据是否具备定案根据资格时,事实认定者应当考虑的某些标准和要求。我国传统的证据三性理论虽将证据合法性纳入审查的实体要素,但在逻辑上,证据三性仅呈平行关系,并无阶层之分,是一种平面思维。这种平面思维导致彰显法律价值的证据合法性在审查时被事实认定者有意忽视。“一旦裁判者发现证据对于发现案件事实真相有意义,就很难下定决心排除非法证据。”^⑪先前曝光的冤假错案中,上述缺陷就体现得较为明显。

正是认识到上述缺陷,我国率先在2010年《排非规定》中确立了非法证据排除规则。^⑫其后,2012年修改的《刑事诉讼法》将非法证据排除规则上升为法律层面的证

^⑩ 参见陈瑞华:《论侦查中心主义》,载《政法论坛》2017年第2期,第3页。

^⑪ 陈学权:《诉讼证据属性的中国表达》,载《法制与社会发展》2024年第1期,第140页。

^⑫ 2010年《排非规定》第1条、第2条和第14条明确规定,非法言词证据和非法物证、书证,不能作为定案的根据。

据规则,并在第56条规定,存在以非法方法收集证据情形的,审判人员应当对证据收集的合法性进行法庭调查。由此,我国改变了传统证据审查的平面思维,将体现证据准入资格的“证据收集的合法性”要素从体现证明力的“证据真实性”要素中区分出来,并将前者作为优先审查的实体要素。非法证据排除规则的确立对我国构建“证据准入—证据评估”二元阶层结构意义重大。首先,从证据审查的思维层面,该规则要求事实认定者丢弃传统的平面审查思维,形成“证据准入—证据评估”的阶层审查思维。其次,从法律依据层面,该规则为事实认定者阶层式审查的运用以及我国证据准入制度的形成提供了明确的法律依据。

其二,确立先行调查规则,为事实认定者优先审查证据收集的合法性提供了程序保障。如果仅有实体规定,欠缺相应的程序保障,证据收集合法性的优先审查在实践中只会沦为事实认定者脑海中的一种思维活动。^⑬为此,有必要设计一种先行调查程序,在此程序中优先审查“证据收集的合法性”要素。我国的制度设计者很早就认识到确立先行调查规则对于贯彻非法证据排除规则的重要性,但受现实因素影响,该规则的确立仍然经历了一个曲折向前的过程。

早在2010年的《排非规定》中,先行调查规则就得到了刚性表达,第5条第1款规定:“被告人及其辩护人在开庭审理前或者庭审中,提出被告人审判前供述是非法取得的,法庭在公诉人宣读起诉书之后,应当先行当庭调查。”这种刚性表达表现在两方面:一是用“应当先行调查”的表述,限制了法庭的裁量权;二是该条款没有规定例外,无论何种情形,法庭都应当优先审查证据收集的合法性。然而,2010年《排非规定》确立的这种刚性表达并没有得到延续。2012年修改的《刑事诉讼法》没有吸收先行调查规则,2012年《刑事诉讼法解释》亦未明确规定该规则,反而采取了退缩立场,将是否先行调查交由法庭根据具体情况裁量。^⑭

或许是意识到采取退缩立场会架空先行调查规则,进而影响非法证据排除规则的贯彻落实,其后不久,制度设计者又放弃了这种立场,改采“原则+例外”的模式,限制法庭决定是否采取先行调查的裁量权。例如,2017年《严格排非规定》和2021年《刑事诉讼法解释》都采取了“原则+例外”的模式。^⑮尽管“原则+例外”的模式限制了法庭的裁量权,但由于对例外的规定用语较为模糊,事实上仍为法庭自由决定是否先行调查容留了空间,这严重影响了先行调查规则的刚性适用。

经过权衡,制度设计者最终在2024年《排非规程》中又对该例外进行了限缩,进一步限制法庭的裁量权。该规程第20条第1款规定:“人民法院决定对证据收集的合法性进行法庭调查的,应当先行当庭调查。对于被申请排除的证据和其他犯罪事实没有关联等情形,为防止庭审过分迟延,可以先调查其他犯罪事实,再对证据收集的合法性进行调

^⑬ 参见罗维鹏:《刑事证据审查标准及其经验》,载《交大法学》2024年第5期,第168页。

^⑭ 参见牟绿叶:《刑事诉讼中的先行调查规则:基础规范与多元构造》,载《法制与社会发展》2024年第4期,第95页。

^⑮ 2017年《严格排非规定》和2021年《刑事诉讼法解释》的表述均为“庭审期间,法庭决定对证据收集的合法性进行调查的,应当先行当庭调查。但为防止庭审过分迟延,也可以在法庭调查结束前(进行)调查。”

查。”根据该条规定,只存在一种例外,即只有在被申请排除的证据和其他犯罪事实没有关联,且调查该证据会导致庭审过分迟延的情况下,才可以不先行当庭调查,除此之外,都应当先行调查。

其三,建立当庭作出决定机制。先行调查规则只是解决了对证据收集的合法性要素进行法庭调查的时点问题,如果调查后法庭迟迟不作出决定,或者推迟至整个法庭调查后再作出证据排除与否的决定,则势必会重蹈覆辙,混淆证据准入和证据评估。为此,在践行先行调查规则的国家和地区,大多要求法庭在先行调查后及时作出决定。例如,英国法官在“预先审核程序”中先行调查系争非法证据后,应当及时对该证据的可采性作出裁决。^{①⑥}根据美国《联邦证据规则》的规定,法官必须在陪审团正式审判前就一个人是否具有作为证人的资格、特免权是否存在以及证据是否可采的预备性问题作出决定。^{①⑦}日本审理前整理程序的证据裁定制度也要求法官及时作出证据是否具备证据能力的裁定。在“GPS 侦查案”中,控辩双方争执警方采取 GPS 定位追踪所取得证据的证据能力。大阪地方裁判所在书面证据裁定中作出决定:GPS 侦查系对目标车辆使用者隐私权的重大侵害,应被视为强制处分,在未取得勘验令状即进行 GPS 侦查所取得的证据及有密切关联性的证据,均无证据能力。^{①⑧}

借鉴比较法上的经验,我国亦开始探索建立当庭作出决定机制。2017 年的《严格排非规定》和《排非规程》分别在第 33 条、第 25 条要求法庭当庭作出决定。^{①⑨}尽管 2021 年《刑事诉讼法解释》没有吸收上述规定,但 2024 年《排非规程》第 28 条第 1 款再次重申了当庭作出决定。

其四,明确规定被排除的证据不得出示、质证。2017 年《严格排非规定》第 34 条第 2 款和 2024 年《排非规程》第 28 条第 2 款均规定,对依法予以排除的非法证据,不得出示、质证,不得作为定案的根据。按照我国刑事诉讼法和相关司法解释的规定,出示、质证是法庭调查证据的合法方式,证据只有经过出示、质证等方式的合法调查,才可以作为定案根据。上述被排除的证据不得出示、质证的规定意味着,被排除的证据当然丧失了准入法庭调查程序成为证据调查对象的资格,进而也丧失了最终作为定案根据的资格。

比较法上亦有类似规定。例如,美国《联邦证据规则》第 103(d)条规定:“在可行的范围内,法院在进行陪审团审判时必须防止以任何方式将不可采的证据暗示给陪审团。”我国台湾地区“刑事诉讼法”第 273 条第 2 款规定:“法院依‘本法’之规定认定无证据能力者,该证据不得于审判期日主张之。”此类规定的目的即在于进一步明确被

^{①⑥} 参见最高人民法院“英国非法证据排除制度”考察团:《英国非法证据排除制度考察报告》,载中华人民共和国最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》(总第 101 集),法律出版社 2015 年版,第 33 页。

^{①⑦} 参见王进喜:《美国〈联邦证据规则(2011 年重塑版)〉条解》,中国法制出版社 2012 年版,第 19 页。

^{①⑧} 参见吴灿:《刑事准备程序有关证据能力意见之处理——兼论“刑事诉讼法”修正草案之证据裁定》,载《月旦裁判时报》第 117 期(2022 年),第 14 页。

^{①⑨} 2017 年《严格排非规定》第 33 条第 1 款:“法庭对证据收集的合法性进行调查后,应当当庭作出是否排除有关证据的决定。必要时,可以宣布休庭,由合议庭评议或者提交审判委员会讨论,再次开庭时宣布决定。”2017 年《排非规程》第 25 条作了一致的表述。

排除证据丧失准入法庭、成为证据调查活动对象的资格,防止法庭违反规定调查证据。

综上所述,非法证据排除规则为法庭从实体上对证据收集的合法性要素进行优先审查提供了法律依据,先行调查规则为法庭的这种优先审查提供了程序保障,当庭作出决定机制要求法庭在先行调查后及时作出决定,防止混淆证据准入和证据评估,明确不得出示、质证的法律后果则进一步防止法庭违反规定调查不具备准入资格的证据。四项措施各负其责、环环相扣、相互支持,共同构筑起我国刑事诉讼中的证据准入制度。

(二) 证据准入制度的核心概念——证据收集的合法性

观察比较法,证据准入制度形成的重要标志是,有一个核心概念指称证据具备准入法庭调查程序、成为证据调查对象的资格。例如,美国的证据准入制度以可采性为核心概念,不具备可采性的证据,丧失准入法庭调查程序的资格。日本和我国台湾地区的证据准入制度以证据能力为核心概念,不具备证据能力的证据,丧失准入法庭调查程序的资格。德国的证据准入制度以可用性为核心概念,^{②①}证据不具备可用性,法庭应当禁止使用该证据。与之类似,我国在构建证据准入制度时,也创设了一个核心概念——证据收集的合法性,^{②②}该概念具备审查和筛选功能,证据符合证据收集的合法性,才可以准入法庭调查程序,反之则丧失准入资格,遑论成为定案根据。然而,对于我国法律创设的这个核心概念,学术界还缺乏细致分析,有鉴于此,笔者将从多个方面分析该概念的规范内涵。

其一,文义分析。从一般文义分析,评价证据收集的合法性应当涉及多个维度,包括证据收集的主体、证据收集的方法、证据收集的程序、证据收集的对象等是否合法。但我国《刑事诉讼法》对证据收集的合法性之含义,采取了限缩解释的立场。《刑事诉讼法》仅从证据收集的方法层面评价证据收集的合法性,即存在“本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的”才不符合证据收集的合法性,而证据收集的其他方面是否合法,并不在证据收集的合法性概念评价范围之内。《刑事诉讼法》第56条是对非法证据及其排除的规定,由此,在我国刑事诉讼中,非法证据和证据收集的合法性互为镜像,形成一组正反概念,属于非法证据就意味着该证据不符合证据收集的合法性,不符合证据收集的合法性就表明该证据是非法证据。

值得注意的是,对“以非法方法收集的证据”之排除范围,司法实务采取了既限缩又扩张的立场。限缩立场表现在,《刑事诉讼法》明确列举的非法方法有四种:刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗,但最高司法机关制定的司法解释和规范性文件仅明确将以刑讯逼供和威胁方法收集的证据纳入应当排除的范围,^{②③}对以引诱和欺骗方法收集的证据是否排除,采取了回避态度,交由法庭裁量。扩张的立场表现在,将《刑事诉讼法》没有明确规定的采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的证据,纳入应当排除的范围。

其二,证据种类分析。《刑事诉讼法》第50条规定了八种证据种类,但仅将物证、书

^{②①} 证据“可用性”(Verwertbarkeit)是德国《刑事诉讼法典》第100d条中的概念,欧洲德语区的研究中也广泛使用,指证据未受证据使用禁止的状态或属性。参见邵奇聪:《证据能力词源考》,载《证据科学》2024年第3期,第313页。

^{②②} 我国《刑事诉讼法》第58、59条中有“证据收集的合法性”的表述。

^{②③} 参见2021年《刑事诉讼法解释》第123条,2024年《排非规程》第1条。

证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解列入证据收集的合法性概念评价范围,鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据则并未列入非法证据排除范围。司法实务中,有法院就以法律没有明确规定为由,拒绝将上述三类证据作为非法证据排除。例如,在“曹某危险驾驶案”中,辩护人申请将血液酒精含量鉴定意见作为非法证据排除。二审法院认为,鉴定意见不属于非法证据范畴,一审法院未召开庭前会议,而是在庭审环节对该鉴定意见进行举证质证,并不存在程序违法问题。^{②③}

其三,证据收集主体分析。证据收集的合法性概念仅适用于国家追诉机关收集的证据,不适用于被告人及其辩护人收集的证据。首先,《刑事诉讼法》第52条“严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法收集证据”的规定中,主语是审判人员、检察人员、侦查人员,并未将被告人及其辩护人涵摄其中。其次,《刑事诉讼法》第59条规定,在对证据收集的合法性进行法庭调查的过程中,人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。按照“谁主张,谁举证”的法理,此处既然明定由人民检察院承担举证责任,则举证对象当然只限于其主张的由追诉机关收集的证据。最后,司法实务中,针对证据收集的合法性展开先行调查的对象均为国家追诉机关收集的证据。如果辩护人收集的证据涉及合法性争议,并不是如追诉机关收集的证据一般,适用先行调查规则,而是在法庭调查程序中通过举证、质证进行调查。例如,在“芦某琴诈骗案”中,辩护人未经对方同意的录音涉及合法性争议,但法庭并未适用先行调查规则,而是在法庭调查程序通过举证、质证调查系争证据。^{②④}

综上所述,作为我国证据准入制度核心概念的证据收集的合法性,具有审查筛选功能,证据符合证据收集的合法性,才可以准入审判期日的法庭调查程序、成为证据调查的对象,反之,则丧失准入资格。但需提及的是,该概念内涵有明显限定,只适用于评价国家追诉机关以非法方法收集的物证、书证等五种证据种类。

三、证据收集的合法性与相关概念的区别

在我国刑事证据理论研究和司法实践中,证据的合法性、可采性、证据能力等概念亦常被使用,这些概念与证据收集的合法性有何区别,有必要进一步阐明。

(一) 证据的合法性与证据收集的合法性

证据的合法性在我国理论研究和司法实践中均有运用。在理论研究层面,代表性证据法学教材均将证据合法性列为证据三性之一。^{②⑤}在司法实践层面,有多个规范性文件提及该概念。例如,2018年最高人民检察院印发的《人民检察院公诉人出庭举证质证工作指引》第40条规定:“质证阶段的辩论,一般应当围绕证据本身的真实性、关联性、

^{②③} 参见新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院(2024)新32刑终88号刑事裁定书。

^{②④} 参见甘肃省兰州市七里河区人民法院(2025)甘0103刑初80号刑事判决书。

^{②⑤} 参见陈光中主编:《证据法学》(第5版),法律出版社2023年版,第119页;樊崇义主编:《证据法学》(第6版),法律出版社2017年版,第128-129页;卞建林主编:《证据法学》,高等教育出版社2020年版,第142-143页。

合法性,针对证据能力有无以及证明力大小进行。”尽管从文字表述上很相近,但证据的合法性与证据收集的合法性是不同概念。

第一,概念来源不同。证据收集的合法性是《刑事诉讼法》明定的概念,证据的合法性则不见之于《刑事诉讼法》条文,而是散见于规范性文件以及学者的著述中。换言之,证据收集的合法性是一个法律规范概念,而证据的合法性则是一个理论研究和司法实践概念。

第二,概念内涵不同。前已指出,证据收集的合法性和非法证据是一组正反概念,证据收集的合法性仅评价证据是否以非法方法收集,因此,该概念的内涵单一而明确。与之相比,证据的合法性概念内涵则显得多元且含混。我国教材通常将证据的合法性解释为证据表现形式符合法定证据种类、证据收集主体合法、证据收集程序和方法合法、经过法定的法庭调查程序四个方面。但也有学者提出,证据合法性要求的具体子要素为收集、固定、保存、审查、运用证据合法。^{②6}亦有观点认为,要将一切影响证据可采性的规范问题均纳入合法性审查。^{②7}无论何种观点,证据合法性的内涵均明显大于证据收集的合法性的内涵。

第三,适用范围不同。首先,就适用的证据种类而言,证据收集的合法性仅限于评价物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解五种证据种类,证据的合法性则不仅适用于评价全部八种证据种类,而且也适用于评价非法定证据种类。例如,在“顾某某故意伤害、非法持有枪支案”中,针对公诉机关提出的由某县刑侦大队出具的情况说明,法院评价认为,该说明仅有一名民警签名,不符合证据的合法性,对该证据,法院不予确认。^{②8}其次,就适用的主体而言,证据收集的合法性仅适用于评价国家追诉机关提出的证据,而证据的合法性不仅适用于评价国家追诉机关提出的证据,也适用于评价被告人及其辩护人提出的证据。例如,在“周某良非法制造爆炸物案”中,法院指出,辩护人提供的电话录音未经被录音人同意,系擅自录制,不符合证据的合法性要件,本院不予采用。^{②9}

第四,功能不同。证据收集的合法性概念具备前置的审查筛选证据功能,只有符合证据收集的合法性,证据才能准入法庭调查程序、成为证据调查对象。证据的合法性则不具备前置筛选证据的功能,其作用主要体现在两方面:一是宏观上的指引作用,即从宏观上运用该概念指引取证主体规范取证;二是微观上的评价作用,即在具体案件的审理中,事实认定者在最后的证据评价环节运用该概念审查判断系争证据可否作为定案根据。当然,也有学者对证据合法性的评价作用提出质疑,认为合法性“不是证据资格评价的标准,即合法的证据未必一律许可(或可采),不合法的证据也未必一律禁止(或排

^{②6} 参见周玉芹:《刑事证据合法性的反思与完善》,载《法学》2025年第5期,第160页。

^{②7} 参见龙宗智:《论我国诉讼证据审查要素及审查方法的调整改革》,载《法学研究》2023年第4期,第184页。

^{②8} 参见云南省墨江哈尼族自治县人民法院(2015)墨刑初59号刑事判决书。

^{②9} 参见湖南省攸县人民法院(2021)湘0223刑初460号刑事判决书。

除)”^⑩。从实践来看,该学者的质疑有一定合理性,这也揭示出证据的合法性概念无力承担前置筛选证据的功能。

(二) 可采性与证据收集的合法性

可采性是英美法系证据法的核心概念,该概念对世界各国的证据制度产生了重要影响,我国有学者即倡导建构以可采性为中心的刑事证据规则体系。^⑪从功能上看,可采性与证据收集的合法性均具有前置的审查筛选证据的作用,但两个概念也有明显区别。

第一,概念内涵不同。证据收集的合法性内涵单一而明确,可采性概念的内涵则多元丰富。首先,相关性寓于可采性之中。在美国,相关性是可采性的前提。其次,除相关性外,影响可采性的因素还包括:(1)证据对诉讼一方所造成的不公正的损害已经超过了它的证明价值;(2)证据对争议事项所造成的混淆;(3)证据对陪审团造成的误导;(4)证据可能导致不适当的诉讼拖延,浪费时间或者不必要地出示重复证据;(5)联邦制定法或者判例法中影响可采性的相关证据规则。^⑫

围绕上述因素,美国又发展出众多的证据规则。例如,围绕相关性审查,发展出品格证据规则、传闻证据规则、意见证据规则、实物证据鉴真规则。基于某些特殊政策考虑设置了特免权规则,基于维护公民宪法权利而发展出非法证据排除规则。当然,对以上因素进行审查时,法院的审查立场不尽相同。一般而言,对自然相关性、不公正损害、混淆、误导等因素的审查,法院采取宽松的立场,目的是让一个证据尽可能地具有可采性,对违反影响可采性的相关证据规则的审查,法院则采取严格的立场。总之,可采性审查的因素远超证据收集的合法性之内涵。

第二,适用的主体不同。英美法系采当事人主义,查明案件事实是控辩双方共同的任务,据此,辩方不仅具有积极收集证据的动力,也享有广泛收集、提交证据的权利。实务中,辩方收集、提交的证据也要受到可采性概念的审查,如果其提交的证据不具备可采性,也将丧失准入法庭的资格。例如,在“康涅狄格州诉阿卜杜拉·萨巴兹案”中,被告准备提出医学专家的证言,证明被害人的死亡是由于医院的医疗过失所致。控方提出动议,要求法庭排除这一证据。在正式庭审前,法庭为此专门举行了听证,弗拉卡斯法官主持了听证。经过听证,弗拉卡斯法官排除了被告提供的专家证言。^⑬

第三,适用的程序不同。首先,就程序运行的时点而言,审查系争证据是否具备可采性的程序一般在正式审判前进行。在美国,控辩双方可以在正式审判前以审前动议的形式请求法院审查证据的可采性。法官可以通过举行听证会的方式,审查系争证据的可采性。当然,如果控辩双方是在正式审判中才对系争证据的可采性产生争执,也可以提出证据异议的方式让法官即时就该问题作出裁决。在英国,由审前的专门程序——预先

^⑩ 史立梅:《我国刑事证据规则体系的范式突破——从“三性两力”桎梏到可靠性规则的体系化再造》,载《政法论丛》2025年第2期,第114页。

^⑪ 参见易延友:《以可采性为中心的刑事证据规则之建构》,载《国家检察官学院学报》2025年第1期。

^⑫ 参见前注^⑪,王进喜书,第62、65页。

^⑬ 参见易延友:《证据法学:原则 规则 案例》,法律出版社2017年版,第128-129页。

审核程序处理证据可采性问题。在该程序中,关于证据可采性的裁决一旦作出,除非经一名法官撤销或改变,在陪审团作出裁决或检察官决定不再进行诉讼之前,都具有约束力。^{③④}与之相比,证据收集的合法性的调查程序是在审判期日的庭审程序开始后举行,在庭审程序前的庭前会议中,法官只能就系争证据收集的合法性听取控辩双方的意见。

其次,就程序启动的门槛而言,我国科以被告人较重的程序启动责任。在我国,被告人欲想让法院启动证据收集合法性的调查程序,应当提供相应的线索或材料。所谓“线索”是指内容具体、指向明确的涉嫌非法取证的人员、时间、地点、方式等。“材料”是指能够反映非法取证的伤情照片、体检记录、医院病历、讯问笔录、讯问录音录像或者同监室人员的证言等。法官审查这些线索和材料,对系争证据收集的合法性产生疑问时,才会启动正式调查程序。对被告人提供线索或材料义务的性质,我国学者有两种解读:一种观点认为是被告人承担的初步举证责任;另一种观点认为是被告人承担的让“审判对象具体化”责任。^{③⑤}而在美国,控辩双方只需对系争证据的可采性提出异议,使该异议成为审理争点就可以促使法官启动调查程序。两相比较,我国被告人承担的程序启动责任无疑更重。

(三) 证据能力与证据收集的合法性

证据能力亦是近年来我国理论研究和司法实践中高频使用的一个概念。理论研究方面,有学者倡导用大陆法系证据法的两个核心概念,即“证据能力”和“证明力”,消除证据三性理论可能带来的误导。^{③⑥}亦有教材用“证据能力/证明力”的两力理论替代了传统的证据三性理论。^{③⑦}在司法实践中,有法官运用“证据能力/证明力”理论审查判断证据。例如,在最高人民法院公布的指导案例——“黄某强贪污案”中,法官在裁判文书中指出,审查判断证据要从两个方面着手:其中之一是审查证据的证据能力。证据必须是合法取得的才具有证据资格,才能作为案件事实认定的依据。^{③⑧}实践中的多份刑事裁判文书也使用了该概念。^{③⑨}尽管证据能力概念使用频繁,但该概念与证据收集的合法性仍有重大区别。

第一,二者性质不同。证据收集的合法性概念是《刑事诉讼法》明确规定的概念,而证据能力概念既没有规定在我国的《刑事诉讼法》中,也没有规定在司法解释中,其只是一个学理概念,不是实定法概念。对此,有学者明确指出,与证明力规范不同,作为审

^{③④} 参见[英]约翰·斯普莱克:《英国刑事诉讼程序》(第9版),徐美君、杨立涛译,中国人民大学出版社2006年版,第350页。

^{③⑤} 参见孙远:《论启动非法证据排除程序的“线索或者材料”——从“质疑责任说”到“审判对象具体化说”》,载《法学论坛》2025年第1期,第22页。

^{③⑥} 参见李勇:《重视证据能力与证明力之证据判断功能》,载《检察日报》2017年12月31日,第3版。

^{③⑦} 参见《刑事诉讼法学》编写组:《刑事诉讼法学》(第4版),高等教育出版社2022年版,第132-134页。

^{③⑧} 参见最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主办:《刑事审判参考》(总第92集),法律出版社2014年版,第103页。

^{③⑨} 笔者以“证据能力”为关键词在“北大法宝”数据库进行搜索,截至2026年5月30日,有1056份刑事裁判文书使用了该概念。

查要素的证据能力尚未得到“两高”司法解释,尤其是最高人民法院司法解释的确认。^{④①}

第二,二者内涵不同。在内涵方面,证据收集的合法性内涵非常明确,仅指准入法庭说,即证据具备证据收集的合法性才可以准入法庭调查程序、成为证据调查对象。与之相比,证据能力的内涵多元且含混。有学者专门统计了关于证据能力含义的四种学说:一是进入法庭说,证据能力等于英美法系的可采性概念,指进入审判法庭的资格;二是定案根据说,证据能力是指作为定案根据的法律资格;三是采纳(标准)说,证据能力是指某个证据在诉讼或其他证明活动中被采纳的资格;四是严格证明资格说,证据能力是指证据在诉讼中可以被用来作为严格证明之依据的法律资格。^{④②}有学者考察了证据能力的词源后甚至指出,证据能力概念的含义不断丰富,结构趋于冗杂,如今已是个指代不明的概念。^{④③}

在要件方面,证据收集的合法性要件单一而明确,仅指未因以非法方法收集而被排除。与之相比,对证据能力的要件,我国学者的见解并不一致。有的学者认为证据能力的要件包括证据的取证主体、证据的表现形式、证据的取证手段、证据是否经过合法的法庭调查程序。^{④④}有的学者认为证据能力要件包括关联性、合法性。^{④⑤}

第三,两者发挥功能的时点不同。证据收集的合法性发挥筛选证据功能的时点是在法庭调查阶段的证据调查前,由于时点靠前,证据收集的合法性发挥的是把守证据作为认定事实依据的“入口”作用。与之相反,我国众多学者认为,证据能力概念发挥的是把守证据作为认定事实依据的“出口”作用。^{④⑥}

四、刑事诉讼证据准入制度存在的问题

历经十余年发展,我国已初步构建起刑事诉讼证据准入制度,形成了符合现代刑事诉讼证据审查发展趋势的“证据准入—证据评估”二元阶层结构,成绩值得肯定。但从比较法、司法实践以及未来改革方向角度审视,该制度在实体和程序方面仍然存在问题。

(一) 实体方面存在的问题

实体方面存在的首要问题是,筛选证据的范围过于狭窄。证据准入制度的功能在于将不适格的证据预先筛选出法庭调查程序,借此保障庭审集中连续高效进行,保障事实认定者能运用适格证据进行证据评价,提升事实认定的准确性。为实现此功能,比较法上适用证据准入制度筛选证据的范围均较为广泛。例如,美国的证据准入制度借助可采性概念,将众多证据纳入筛选范围,具体包括:不具备相关性的证据、适用非法证据规则

^{④①} 参见前注②⑦,龙宗智文,第172页。

^{④②} 参见林志毅:《论刑事证据资格之多重性》,载《中国法学》2022年第1期,第263页。

^{④③} 参见前注②⑩,邵奇聪文,第324页。

^{④④} 参见陈瑞华:《刑事证据法》(第3版),北京大学出版社2018年版,第136-139页。

^{④⑤} 参见万毅:《论无证据能力的证据——兼评我国的证据能力规则》,载《现代法学》2014年第4期,第139页。

^{④⑥} 参见纵博:《我国刑事证据能力之理论归纳及思考》,载《法学家》2015年第3期,第74页。

排除的证据、造成不公正损害超过其证明价值的证据、容易混淆争议事项以及误导陪审团的证据、严重影响庭审效率的证据。相比之下,我国仅将以非法方法收集的证据纳入筛选范围,放任大量不适格的证据涌入法庭调查程序,阻碍了证据准入制度功能的发挥。

实际上,除了违反《刑事诉讼法》第56条规定,以非法方法收集的证据之外,从规范和实务角度观察,证据准入制度还可以适用于其他类型的不适格证据。

一是以两种特殊类型的犯意引诱方式收集的证据。2023年最高人民法院印发的《全国法院毒品案件审判工作会议纪要》规定,隐匿身份人员向被引诱人提供毒品或者毒资、购毒渠道的,其所提供的毒品、毒资、被引诱人从其提供的渠道购买的毒品及其证实被引诱人实施毒品犯罪的证据材料,不得作为认定被引诱人实施毒品犯罪的证据。据此,以上述方式收集的证据,包括隐匿身份人员提供的毒品、毒资和被引诱者从指定渠道购买的毒品、毒品提取、扣押笔录、毒品鉴定意见、通话记录或录音、被引诱者的供述、隐匿身份人员的证言均应预先排除。^{④6}

二是犯罪嫌疑人认罪认罚反悔后,之前签署的认罪认罚具结书及作出的认罪供述。2026年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第59条规定:“犯罪嫌疑人认罪认罚,签署认罪认罚具结书,在人民检察院提起公诉前反悔的,具结书失效,人民检察院应当在全面审查事实证据的基础上,依法提起公诉。”据此,犯罪嫌疑人在提起公诉前反悔的,认罪认罚具结书失去法律效力。此外,由于犯罪嫌疑人反悔,其之前作出的认罪供述丧失了自愿性基础,不应准入法庭调查程序成为证据调查对象。

三是不具备证人资格的自然人所作的证言。《刑事诉讼法》第62条第2款规定:“生理上、精神上有缺陷或者年幼,不能辨别是非、不能正确表达的人,不能作证人。”2021年《刑事诉讼法解释》第88条第1款规定:“处于明显醉酒、中毒或者麻醉等状态,不能正常感知或者正确表达的证人所提供的证言,不得作为证据使用。”据此,不具备证人资格的自然人所作的证言不应准入法庭调查程序成为证据调查对象。

四是一般证人的意见证据。2021年《刑事诉讼法解释》第88条第2款规定:“证人的猜测性、评论性、推断性的证言,不得作为证据使用,但根据一般生活经验判断符合事实的除外。”据此,一般证人的意见证据不应准入法庭调查程序成为证据调查对象。

五是使用范围有明确限制的境外证据。2021年《刑事诉讼法解释》第77条第1款规定:“对来自境外的证据材料,人民检察院应当随案移送有关材料来源、提供人、提取人、提取时间等情况的说明。经人民法院审查,相关证据材料能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的,可以作为证据使用,但提供人或者我国与有关国家签订的双边条约对材料的使用范围有明确限制的除外。”据此,使用范围有明确限制的境外证据不应准入法庭调查程序成为证据调查对象。

^{④6} 参见方文军:《诱惑侦查的类型及其法律后果——以2023年毒品犯罪“昆明”会议纪要为中心展开》,载《法律适用》2024年第2期,第116页。

六是《刑事诉讼法解释》规定的其他类型的不适格证据。2021年《刑事诉讼法解释》还规定了众多不能作为定案根据的证据,这类证据之所以不能作为定案根据,并非由于证明力原因,而是由于违反相关取证程序规范,丧失定案根据资格。例如,讯问未成年人时其法定代理人或者合适成年人不在场的被告人供述,辨认活动没有个别进行的辨认笔录等。实际上,以上证据并不涉及证明力调查及评价问题,完全可以适用证据准入制度,阻止其进入法庭调查程序,从而间接达到剥夺其作为定案根据资格的目的。

七是司法实务中,法官通过司法续造方式认定的不适格证据。法官进行司法续造是促进法律发展的重要途径。^{④7}在刑事诉讼中,取证程序规范种类繁多,国家公权力机关违反取证程序规范收集的证据是否应排除使用,法律不可能巨细靡遗地明确规定。在此情形下,法官可以运用司法续造的各种方法去发展法律。观察我国司法实践,存在一些法官通过司法续造方式认定的不适格证据。例如,《刑事诉讼法》第150条规定,公安机关应当在立案后,经过严格的批准手续,才可以采取技术侦查措施。如果公安机关违反上述取证程序规范收集证据,该证据是否排除使用,《刑事诉讼法》并未明确规定。对此,在“罗某成贩卖毒品案”中有法官指出,公安机关使用技术侦查措施的时间早于立案时间,不符合刑事诉讼法规定,所收集的证据不能作为定案根据。^{④8}

总体而言,以上列举的不适格证据皆不涉及证明力调查及评价,完全可以将这些证据纳入证据准入制度适用范围,预先将其筛选出法庭调查程序。如此操作,既可节省庭审资源、提升庭审效率,又可以防范心证污染、保障裁判者准确认定事实。然而,由于现阶段我国证据准入制度的适用范围过于狭窄,以上列举的种种证据并未纳入适用范围,导致大量不适格证据涌入法庭调查程序、成为证据调查对象,靡费诉讼资源、混淆庭审重点,增加了裁判者不当评价证据证明力、错误认定案件事实的风险。例如,在“马某罗贩卖毒品、容留他人吸毒案”中,公诉机关在法庭调查环节出示了证人的辨认笔录,辩护律师提出抗辩,证人的辨认活动没有个别进行,该辨认笔录应当排除使用。法院查明,辨认活动没有个别进行,该辨认笔录不得作为定案的根据。^{④9}实际上,对该辨认笔录,审判期日的法庭调查程序根本没有围绕其证明力展开调查,完全可以适用证据准入制度,预先将其筛选出法庭调查程序,并无必要任其进入法庭调查程序,徒耗庭审资源、混淆庭审重点。

与上述问题紧密关联的是,我国刑事证据准入制度选择的核心概念——“证据收集的合法性”并不适宜。

一是该概念内涵单一、明确,无法适应从多个层面审查筛选证据的发展趋势。无论是英美法系还是大陆法系,证据准入制度选择的核心概念在表述上都具有共同特征,即表述都偏于中性,且内涵较为丰富。英美法系选择的可采性概念是从结果角度确定的中性表述,且该概念内涵丰富,能让法官从相关性、非法证据、外部政策因素等多个方面审查筛选证据。大陆法系选定的证据能力概念,是从资格具备角度确定的中性表述,这种

^{④7} 参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》(第6版),黄家镇译,商务印书馆2020年版,第460页。

^{④8} 参见新疆维吾尔自治区高级人民法院(2014)新刑三终105号刑事判决书。

^{④9} 参见四川省盐边县人民法院(2017)川0422刑初26号刑事判决书。

中性表述能让法官从证据的取证主体、证据的表现形式、证据的取证手段等多方面审查证据是否具备准入法庭调查程序的资格。反观我国证据准入制度选择的证据收集的合法性概念,其内涵过于单一,只聚焦于证据收集的方法是否属于法定的非法方法,无法承担从多个层面审查筛选证据的重任。

二是概念文义和内涵不匹配,且容易与传统三性理论中“证据的合法性”混淆。从文义分析,证据收集的合法性内涵应当包括多个维度,如证据收集主体的合法性、证据收集对象的合法性、证据收集手段的合法性、证据收集程序的合法性等。然而,我国立法机关却将证据收集的合法性内涵限定于证据收集方法的合法性这一单一维度,导致了概念文义和内涵的差异,容易引发误解。而且,证据收集的合法性与传统三性理论中证据的合法性概念表述相近,容易产生混淆。前已论及,证据收集的合法性与证据的合法性虽然表述相近,实则差异较大,但正因为二者表述相近,导致在理论研究^⑩和司法实践^⑪中极易出现混淆使用的现象,凡此种均不利于法律概念的规范表达。

(二) 程序方面存在的问题

程序方面存在的问题首先主要表现为,审查证据准入的程序时点较为靠后,不利于审判期日的庭审程序集中连续高效进行。比较法上,证据准入审查程序一般设置在庭前准备程序中,与之相比,我国虽然确立了先行调查规则,但证据准入审查程序仍然设置在审判期日的庭审程序中,只是将庭审程序划分为两个阶段,前一阶段先行调查证据收集的合法性,后一阶段再调查证据的真实性和可信性。在笔者看来,这种设计并不利于庭审程序集中连续高效进行,原因是,在某些重大疑难复杂案件中,合议庭并不能当庭决定证据是否排除使用,必须留待休庭后评议或者提交审判委员会讨论后才能作出决定。2024年《排非规程》第28条第1款规定:“人民法院对证据收集的合法性进行调查后,应当当庭作出是否排除有关证据的决定。必要时可以宣布休庭,由合议庭评议或者提交审判委员会讨论,再次开庭时宣布决定。”从该规定可见,合议庭有可能因为需要留待庭后评议或者提交审判委员会讨论而中断庭审程序,因为不如此操作,相关证据的准入资格就不明确,后续的证据调查程序就无法进行。但如此一来,势必会中断庭审程序,影响庭审程序集中连续高效进行。在“白某刚受贿案”中,被告人及其辩护人申请排除非法证据,合议庭在庭审中就相关证据收集的合法性先行进行了调查,但未当庭作出决定,而是休庭后经合议庭评议后再提交审判委员会讨论。^⑫由此可见,庭审程序确因留待合议庭庭后评议或者提交审判委员会讨论决定而被迫中断,这种程序设计显然不利于庭审程序集中连续高效进行。

^⑩ “对此,应将实质性排非程序前置至庭前会议中,并按照庭审规则进行证据合法性调查”,实则此处应当使用证据收集的合法性概念。参见前注^⑥,周玉芹文,第160页。

^⑪ 例如,在“王某某诈骗案”中,判决书载明:“为此,本院召开了庭前会议,并在开庭审理过程中,依法对证据收集的合法性进行了先行调查,公诉机关就证明该份证据的合法性出示了侦查机关出具的情况说明,相关侦查人员亦到庭接受发问。”该判决书前面使用证据收集的合法性概念,后面又用证据的合法性表述。参见天津市南开区人民法院(2019)津0104刑初194号刑事判决书。

^⑫ 参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2018)辽01刑终296号刑事裁定书。

其次,就程序启动的门槛而言,我国科以被告人较重的程序启动责任。比较法上,被告人只需要对控方所提出证据的准入资格持有异议,即可促使法官开启相应的审查程序。所谓有异议,是指对控方所提出证据的准入资格,被告人持否定态度并释明理由。例如,德国的“私人秘密录音案”中,被告人即是提出证据调查异议,反对法庭播放被害人女友秘密录制的录音带,最终促使法庭审查后作出裁定,不予调查该证据。美国《联邦证据规则》第103条也规定,被告只需提出异议并说明理由,就可促使法官调查该证据的可采性。^{⑤③}在我国台湾地区,被告人只要对证据的证据能力有所争执,且释明理由,即可促使法庭开启调查程序。^{⑤④}

与之相比,我国并未采取异议模式,而是要求被告提供相应的线索或材料,才能促使法院启动证据收集合法性的调查程序。但由于实践中被告人大都处于侦查机关单方控制的封闭环境中,即使其遭受了非法取证,也很难提供具体的、有价值的线索,加之,法官对何为“相应的线索或材料”具有一定程度的裁量权,故有相当部分的非法证据排除申请被法官否决。^{⑤⑤}并且,对被告人应当“提供相应的线索或材料”这一责任,法律和司法解释未明确其性质,导致实务中法官可能会不当加重被告人的程序启动责任,影响证据收集合法性调查程序的启动。

五、刑事诉讼证据准入制度的完善

以非法证据排除规则的确立及其随后的程序发展为契机,我国已初步构建起刑事诉讼证据准入制度,但从比较法和以审判为中心的刑事诉讼制度改革方向角度审视,这一制度还存在不足之处,有待进一步完善。

(一) 适当扩大证据准入制度筛选证据的范围

现行证据准入制度仅将国家公权力机关以非法方法收集的证据纳入筛选范围,较为狭窄,未来有必要扩大证据筛选范围。首先,扩大证据筛选范围是顺应证据发展趋势的需要。正如前述,比较法上建立证据准入制度的国家和地区筛选证据的范围都较为广泛,不仅包括以非法方法收集的证据,还包括严重违反取证程序收集的证据、违反特定证据规则取得的证据,甚至还包括有可能引起事实认定者偏见的证据及导致诉讼拖延的证据。

其次,扩大证据筛选范围也是推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的需要。以审判为中心的实质是要以庭审为中心,保证庭审在查明事实、认定证据中发挥决定性作用,^{⑤⑥}为此,应将庭审重心集中于调查证据的真实性和可信性上。扩大证据筛选范围,可以将那些不涉及证据真实性和可信性问题,只涉及证据资格问题的不合格证据预先筛选

^{⑤③} 参见前注①⑦,王进喜书,第11页。

^{⑤④} 参见叶建廷:《刑事准备程序中证据能力之调查与认定》,载《检察新论》第3期(2008年),第180页。

^{⑤⑤} 参见左卫民:《“热”与“冷”:非法证据排除规则适用的实证研究》,载《法商研究》2015年第3期,第155页。

^{⑤⑥} 参见戴长林、刘静坤:《〈关于全面推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革的实施意见〉的理解与适用》,载《人民司法(应用)》2017年第10期,第23页。

出法庭调查程序。如此一来,法庭才可以集中精力,重点围绕证据的证明力展开调查,不因控辩双方反复争执证据的资格问题而偏离法庭调查重心,确保庭审实质进行。

就扩大的具体范围而言,有必要将前述分析总结的七种类型证据纳入证据准入制度的筛选范围。此外,如果未来刑事诉讼法修改增加了新的涉及证据资格的规则,如品格证据规则、传闻证据规则、近亲属作证特权规则等,也应当将相关证据纳入筛选范围。事实上,司法实务中已有法官扩大了证据准入制度的筛选范围,将不属于以非法方法收集的证据也纳入先行调查处理的程序中,这说明扩大证据筛选范围具有实践可行性。在“张某影危险驾驶案”中,辩护人申请将某司法鉴定所出具的鉴定意见作为非法证据予以排除,理由是鉴定意见书系未加盖资质认定标志的检验检测报告。法庭在先行调查程序中调查了该鉴定意见书的证据资格问题,最终认定意见书具有证据资格,公诉方可以在庭审中出示。^{⑤7} 尽管该鉴定意见最终被认定具有证据资格,但法庭确实在先行调查程序中扩大了证据准入制度的筛选范围。

最后,扩大证据筛选范围也是适应人民陪审员制度改革的需要。根据《人民陪审员法》第14条的规定,人民陪审员可以加入三人合议庭(2+1或者1+2)或者七人合议庭(3+4)参与庭审。不论何种组织形式,人民陪审员均享有独立的事实认定权。由于人民陪审员没有接受过专门的法律训练,较难抵御不适格证据对心证产生的不当影响。“对于不具备法律专业素养及审判经验的‘素人’——参与审判的国民而言,是否要让渠等接触没有证据能力或调查必要性的证据,就有非常重大的意义。盖对于‘素人’而言,要让一个具备高度证据价值、但却没有证据能力的证据从心中完全抹去,不要影响心证形成,实在是非常困难的工作。”^{⑤8} 为此,有必要通过前置的证据准入制度,将有可能污染人民陪审员心证的不适格证据预先筛选出去,为人民陪审员正确评价证据、准确认定案件事实提供必要的程序保障。

与扩大证据筛选范围相适应,未来我国刑事诉讼法修改时应当增加法官排除使用证据的裁量权。目前,我国司法实务中虽偶有法官以司法续造方式发展了排除使用证据的类型和情形,但由于欠缺制定法的规定,裁量权行使的依据和正当性不足。为此,有必要在刑事诉讼法中增设证据排除的概括授权条款,作为法官裁量认定证据是否具备准入资格的法律依据。对此,2003年我国台湾地区修改“刑事诉讼法”时,专门于第158条之4增订证据排除概括授权条款,规定:“除法律另有规定外,实施刑事诉讼程序之公务员因违背法定程序取得之证据,其有无证据能力之认定,应审酌人权保障及公共利益之均衡维护。”该条“立法理由”指出,在判断证据有无证据能力问题时,应当衡量下列七种情形:(1)违背法定程序之情节;(2)违背法定程序时之主观意图;(3)侵害犯罪嫌疑人或被告权益之种类及轻重;(4)犯罪所生之危险或实害;(5)禁止使用该证据对于

^{⑤7} 参见安徽省宿州市埇桥区人民法院(2024)皖1302刑初941号刑事判决书。

^{⑤8} 张永宏:《论证据裁定制度——兼从国民参与审判制度的角度思考》(上),载《司法周刊》第1589期(2012年),第7页。

预防将来违法取得证据之效果；（6）侦查人员如依法定程序有无发现该证据之必然性；（7）证据取得之违法对被告诉讼防御不利益之程度。^{⑤⑨}

（二）将证据的适格性确定为证据准入制度的核心概念

原有的证据收集的合法性概念因其内涵单一，已无力承担范围扩大后的筛选证据功能，在扩大证据筛选范围的前提下，有必要重新确定我国刑事诉讼证据准入制度的核心概念。那么，能否以可采性、证据能力和证据合法性概念代替证据收集的合法性概念呢？在笔者看来，上述概念均有不足。

首先，可采性概念是源于英美法系国家证据准入制度的核心概念，在构建中国法学自主知识体系的大背景下，直接引进异于我国诉讼构造的他国法律制度中的核心概念，容易引发争议。2012年修改的《刑事诉讼法》引入英美法系“排除合理怀疑”概念，用以解读我国刑事有罪证明标准“证据确实、充分”，由此引发的争议即为明证。^{⑥⑩}其次，证据能力概念虽源于与我国诉讼构造更具亲缘性的大陆法系国家，且在我国理论研究中使用的频繁，但我国学者对该概念的内涵和要件认识并不一致，直接应用也容易引发误解。例如，有的学者认为证据能力是指进入法庭的资格，^{⑥⑪}有的学者认为证据能力是指作为定案根据的资格^{⑥⑫}。如果将其定位为作为定案根据的资格，则该概念根本不能发挥前置筛选证据的功能，何谈成为证据准入制度的核心概念。最后，证据合法性概念属于传统证据三性理论范畴，三性说对证据合法性的阐释，与立法和司法实践存在脱节，很难让其承担筛选证据的功能。^{⑥⑬}加之，证据三性理论是一种平面审查思维，将体现平面审查思维的证据合法性概念作为“证据准入—证据评估”二元阶层结构的核心概念，有可能会弱化该结构的阶层审查功能。

舍弃上述三个概念后，笔者认为，可将证据的适格性确定为证据准入制度的核心概念。证据的适格性是指，证据具备准入法庭调查程序、成为证据调查对象的资格。选择证据的适格性作为核心概念，主要有如下优点：

首先，表述中性、兼容性强，可以满足从多个维度审查筛选证据的需要。前已指出，比较法上证据准入制度在选择核心概念时都体现出一个共同特征，即表述都偏于中性，且内涵较为丰富，英美法系的可采性和大陆法系的证据能力都具有这个特征，也只有具备这个特征，才可以便利法官从多个维度审查筛选证据，决定系争证据是否具备准入法庭的资格。证据的适格性正好满足这一特征，表述上较为中性且内涵丰富，在扩大证据筛选范围的背景下，能让法官从不同维度审查系争证据的准入资格。例如，法官可以系争证据是以非法方法收集，违反刑事诉讼法的禁止性规定为由，认定该证据不具备适格

^{⑤⑨} 参见黄朝义：《刑事诉讼法》（第5版），新学林出版股份有限公司2017年版，第608页。

^{⑥⑩} 参见李训虎：《“排除合理怀疑”的中国叙事》，载《法学家》2012年第5期；龙宗智：《中国法语境中的“排除合理怀疑”》，载《中外法学》2012年第6期。

^{⑥⑪} 参见郑飞：《证据属性层次论——基于证据规则结构体系的理论反思》，载《法学研究》2021年第2期，第130页。

^{⑥⑫} 参见前注^{⑤⑪}，纵博文，第76页。

^{⑥⑬} 参见前注^{⑤⑪}，陈学权文，第138页。

性,不得准入法庭调查程序成为证据调查对象。法官还可以系争证据违反某些证据规则如意见证据规则、品格证据规则,认定该证据不具备适格性。对于某些明显无关联性和无调查必要性的证据,法官也可以系争证据不具备适格性,预先将其筛选出法庭调查程序。相比之下,现在使用的证据收集的合法性概念因其内涵单一,无法为法官从多个维度审查筛选证据提供帮助。

其次,能最大程度地体现可采性和证据能力所共有的证据准入资格属性,发挥前置把关功能。有学者指出,大陆法系的证据能力和英美法系的可采性,二者本质上没有区别,均指证据的适格性,是法律拟制的证据准入资格。^④将证据的适格性确定为核心概念,既能吸收比较法上的共同经验,又不至于盲目照搬法律概念,有利于构建中国刑事诉讼法学自主知识体系。

(三) 构建以庭前会议为主的证据准入审查程序

在扩大证据筛选范围的背景下,相关国家和地区大都倾向于以庭前准备程序来审查处理证据是否具备准入资格。如果我国朝着扩大证据筛选范围的趋势发展,则目前的在庭审程序中先行调查决定证据准入资格的做法就需要调整,因为这种做法会混淆法庭调查程序的重点,不利于庭审程序集中连续高效进行。

可行的改革方案是,发挥庭前会议审查筛选证据的功能,构建以庭前会议为主的证据准入审查程序。有论者指出:“完全的庭中排除使得庭审活动偏离了定罪量刑的主题……庭审的中心功能没有实现。为避免诉讼资源被无谓地浪费,非法证据排除申请的提出应当被适度引导……有必要充分利用庭前会议程序,尽量在庭前解决非法证据排除问题。”^⑤实际上,我国的庭前会议已经初步具备预先调查证据准入资格的功能。2024年最高人民法院印发的《办理刑事案件庭前会议规程》(以下简称2024年《庭前会议规程》)第15条第1款规定:“人民检察院应当在庭前会议中通过出示有关证据材料等方式,有针对性地对证据收集的合法性作出说明。人民法院可以对有关证据材料进行核实;经控辩双方申请,可以有针对性地播放讯问录音录像。必要时,可以通知侦查人员或者其他人员参加庭前会议,说明情况。”2024年《严格排除规程》第14条规定:“在庭前会议中,人民法院对证据收集的合法性进行审查的,一般按照以下步骤进行:(一)被告人及其辩护人宣读排除非法证据的申请并提供相关线索或者材料;(二)公诉人提供证明证据收集合法性的证据材料;(三)控辩双方对证据收集的合法性发表意见;(四)控辩双方对证据收集的合法性未达成一致意见的,审判人员归纳争议焦点。”从以上规定可见,庭前会议已经具备调查功能,法庭完全可以在庭前会议中预先调查并决定系争证据的证据准入资格。

然而,在已经赋予庭前会议调查证据准入资格功能的同时,司法解释仍规定在审判期日的庭审程序中进行可能的重复调查。例如,2024年《严格排除规程》第17条第2

^④ 参见前注^⑥,郑飞文,第125页。

^⑤ 江必新主编:《〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释〉理解与适用》,中国法制出版社2013年版,第100页。

款规定：“控辩双方在庭前会议中对证据收集的合法性未达成一致意见，人民法院对证据收集的合法性有疑问的，应当在庭审中进行调查。”既然庭前会议已经进行了先期调查，如果人民法院仍有疑问，完全可以继续依托庭前会议进行调查，何必留待庭审程序调查？之所以有上述不协调的规定，可能的原因之一是，对《刑事诉讼法》的相关规定理解存在偏差。《刑事诉讼法》第58条规定：“法庭审理过程中，审判人员认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，应当对证据收集的合法性进行法庭调查。”由于《刑事诉讼法》要求审判人员对证据收集的合法性进行法庭调查，因此制度设计者可能认为，对证据收集的合法性的调查处理应当放置在庭审程序的法庭调查环节。实际上，《刑事诉讼法》的这一规定只是指示审判人员应当对证据收集的合法性问题履行调查义务而不能回避这一问题，至于调查的程序时点和方式，《刑事诉讼法》并没有限定。

从证据法理而言，依待证事实性质不同，可将证明分为严格证明和自由证明。对犯罪事实等实体事实的证明，适用严格证明方法，须以法定证据方法为之，且须依托审判期日的法定调查程序进行。对有无管辖权、是否合法告诉等程序性事项，适用自由证明方法，无需遵守法定证据方法和法定调查程序的要求。此外，审判程序以外无论是关于实体或程序事项的认定，皆适用自由证明方法。^{⑥6}证据准入资格的审查属于程序事项的证明和认定，完全可以适用自由证明，不必留待审判期日的庭审程序以严格证明方法调查。可见，从证据法理而言，在庭前会议中法官以自由证明方法审查系争证据的准入资格并不存在理论障碍，以此种方式调查，足以履行《刑事诉讼法》指示的调查义务。

因此，我国应当继续充实完善庭前会议已有的预先调查证据准入资格的功能，构建以庭前会议为主的证据准入审查程序。对于审查事项较为简单的情形，法官可采取“书面阅卷+听取意见”的方式决定证据的准入资格。如果审查事项较为复杂，则可沿用目前庭前会议调查证据收集的合法性的方式。无论何种情形，均应在审判期日的庭审程序开始前决定系争证据的准入资格。系争证据被认定不具备准入资格的，控辩双方不得在审判期日的庭审程序出示、质证。如果控辩双方在庭审过程中才提出证据资格异议，应当说明理由。理由成立且法庭对系争证据的资格有疑问的，法庭应当先行审查。如果审查的事项较为复杂，可能中断庭审，法庭可以休庭，以再次开庭前会议的方式调查处理。^{⑥7}再次开庭前会议时，法庭应聚焦系争证据的证据准入资格问题，不得调查该证据的实质信息内容。

（四）采取“异议+释明”模式减轻被告人的程序启动责任

我国目前科以被告人较重的程序启动责任，在扩大证据筛选范围，构建以庭前会议为主的证据准入审查程序的大背景下，有必要减轻被告人的程序启动责任，改采“异议+释明”模式，即只要被告人对系争证据的准入资格提出异议，并说明理由，即可促使法庭

^{⑥6} 参见林钰雄：《刑事诉讼法》（上），新学林出版股份有限公司2017年版，第513页。

^{⑥7} 2024年《庭前会议规程》第7条：“根据案件情况，庭前会议可以在开庭审理前多次召开；休庭后，可以在再次开庭前召开庭前会议。”根据该规定，法庭可以在庭审休庭后再次召开庭前会议。

开启证据准入资格的审查程序。这一模式除了顺应比较法上的发展趋势以外,还可得到如下理由的支持:

其一,对管辖、回避等程序性事项启动审查,我国采取的是“异议+释明”模式,2024年《庭前会议规程》第12条、第13条规定可谓明证。^⑧证据准入资格问题既然属于程序性事项,理应沿用这一模式,只要被告人及其辩护人对控方准备提出证据的准入资格有异议,并说明异议理由,法院就应开启相应的审查程序。

其二,我国目前将证据收集的合法性调查程序嵌入审判期日的庭审程序中,使该程序从属于庭审程序,考虑到庭审程序对程序性的要求较为严格,易耗资源,不应轻易启动,为此,立法者才科以被告人较重的程序启动责任。但依据前述制度设计,证据准入资格调查处理程序从审判期日的庭审程序分离,置于庭前会议中。鉴于庭前会议召开灵活,方式简便,采取“异议+释明”不致过度耗费诉讼资源,且有利于减轻被告人的程序启动责任。

Abstract: In modern criminal procedure, admission of evidence refers to the court's review of whether evidence is qualified to enter the court's investigative procedure at trial and become the subject of evidence examination. After more than a decade of development, China has initially established an evidence admissibility system in criminal procedure, forming a dual-tier structure of 'evidence admissibility — evidence assessment' that conforms to the global trend of modern criminal evidence review. Nevertheless, from the perspectives of comparative law, judicial practice, and future reform orientation, several deficiencies persist in both substantive and procedural aspects of this system. Going forward, China shall further improve the system by taking such measures as appropriately expanding the scope of evidence screened by the evidence admissibility regime, establishing admissibility of evidence as the core concept, constructing a pretrial conference-centered procedure for reviewing evidence admissibility, and adopting an objection plus clarification model to reduce the defendant's burden of initiating the relevant procedure.

(责任编辑:王 楷)

^⑧ 2024年《庭前会议规程》第12条:“被告人及其辩护人对案件管辖提出异议,应当说明理由。人民法院经审查认为异议成立的,应当依法将案件退回人民检察院或者移送有管辖权的上一级人民法院审判;认为本院不宜行使管辖权的,可以请求上一级人民法院处理。人民法院经审查认为异议不成立的,应当依法驳回异议。”第13条:“被告人及其辩护人申请合议庭组成人员、法官助理、书记员、鉴定人、翻译人员回避,应当说明理由。人民法院经审查认为申请成立的,应当依法决定有关人员回避;认为申请不成立的,应当依法驳回申请。”